

1515902-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Dispõe o aludido dispositivo que: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515902-79.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515902-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177307/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 18809829 - 24º D.P. PONTE RASA, 2869/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2177307 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS VICTOR FREIRE ALMEIDA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS VICTOR FREIRE ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI (corrupção de adolescente para o tráfico), ambos da Lei 11.343/06, e c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na tarde de 30 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Francisco Dantas nº 215, Cangaíba, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso com os adolescentes Vitor Tavares França e Gabriel Sampaio de Vasconcelos, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, em ocasião de calamidade pública, para o

tráfico de drogas, 67 (sessenta e sete) embalagens de plástico contendo cocaína, 17 (dezesete) porções de maconha e 36 (trinta e seis) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 96,50 (noventa e seis reais e cinquenta centavos), em espécie, proveniente da atividade criminosa (V. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22 e Laudo Pericial de fls. 56/61).

Consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Vitor Tavares França e Gabriel Sampaio de Vasconcelos, à época contando com dezessete e quinze anos de idade, respectivamente, com eles praticando as infrações penais mencionadas.

É da inicial que, segundo apurado nos autos, o denunciado e os adolescentes foram vistos por policiais militares no ato de carregar sacolas plásticas, aparentando estarem em atividade de traficância. Ao notarem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga em sentido a uma viela, porém não tiveram êxito.

Narra a denúncia que, feita a abordagem, foram encontradas tanto com os adolescentes quanto com o denunciado, diversas porções das drogas destinadas à venda e a quantia de R\$ 96,50 (noventa e seis reais e cinquenta centavos) em notas de pequeno valor, produto da traficância (V. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 21/22).

Extraí-se da exordial que, indagado, o adolescente Gabriel Sampaio de Vasconcelos admitiu que trazia a droga para venda no local (V. Termo de Declarações de fls. 19). Já o adolescente Vitor Tavares França negou trazer a droga consigo, dizendo que apenas era usuário e que estava no local para comprar os entorpecentes (V. Termo de Declarações de fls. 18).

Relata a inicial que interrogado pela Autoridade Policial, CARLOS negou ter trazido consigo as drogas, afirmando que os entorpecentes estavam na posse dos adolescentes (V. Termo de Interrogatório de fls. 20).

Por fim, é da denúncia que a droga foi apreendida e submetida ao exame pericial, sendo o resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (V. Laudo de constatação de fls. 50/55).

Por decisão exarada no dia 01 de julho de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e concedida liberdade provisória ao denunciado (fls. 81/84).

O Alvará de Soltura Clausulado foi cumprido por não haver impedimento (fls. 91/94).

O réu foi citado (fl. 138).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 143).

A denúncia foi recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, pois não há provas de que o réu tenha envolvido os adolescentes Gabriel e Vitor na suposta traficância,

ressaltando-se que os adolescentes sequer foram ouvidos em juízo para que fosse possível averiguar suas condições pessoais ou mesmo as circunstâncias em que teriam em tese participado do crime; e) a outorga de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; f) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07/08), Boletim de Ocorrência (fls. 09/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21/22), Laudo de Constatação (fls. 56/61), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado dos Itens 1, 4 e 5) e tetrahydrocannabinol (resultado dos Itens 2 e 3), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 109/112), bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/112) que foi detectada a presença das substâncias a) cocaína no item 1, com total de 5,4 gramas; b) tetrahydrocannabinol, nos itens 2 e 3, com respectivamente 7,7 gramas e 1,8 gramas, c) cocaína nos itens 4 e 5, com respectivamente 12,7 gramas e 13 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha André Luis Coutinho Tarsitano, policial militar, narrou, em suma, que nesse dia era o comandante da viatura e estava em patrulhamento. Avistaram os três indivíduos, Carlos, Vitor e Gabriel em atitude suspeita pela via, estavam com alguma coisa na mão e sacolinha na mão. Os três estavam juntos. Atrás da rua é uma comunidade e a região é conhecida pelo tráfico de drogas. Quando chegaram perto deles, os três correram. Correram atrás dos três e conseguiram alcançá-los. Encontraram entorpecentes e dinheiro com os três. Com os três tinha maconha, cocaína e crack, em "plastiquinhos" e "eppendorfs". Tinha dinheiro com os três. Eles disseram que estavam mesmo na prática. Fez apreensão de Gabriel na mesma região posterior a essa data. Na época Vitor e Gabriel eram adolescentes e os três confessaram que estariam ali comercializando os entorpecentes. No momento que fizeram a apreensão, pediram apoio de viaturas e até as viaturas chegarem, Carlos meio que estava ameaçando os dois menores para não dizerem nada.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Isac Rodrigues de Almeida Junior, policial militar, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e tinham três indivíduos pela via. A hora que a viatura adentrou os três saíram correndo. Conseguiram fazer a detenção dos três e os três tinham entorpecentes e dinheiro. Tinha maconha, cocaína e crack. A droga estava com os três. Se não se engana tinham dois menores e falaram que um deles era o primeiro dia, o outro estava há um tempinho. Na condução para a delegacia o réu estava falando para os menores que se "caguetassem" iria conversar com os menores.

Apesar de intimado (fl. 138), o réu não compareceu em audiência, tendo sido decretada a sua revelia.

Diante de todo conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo réu na fase policial restou isolada, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância do réu CARLOS foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (crack, maconha e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (5,4g de crack, 9,5g de maconha e 25,7g de cocaína); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pela apreensão de dinheiro; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a natureza de entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Dispõe o aludido dispositivo que: “Art. 40 - As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”. (grifos nossos).

Restou demonstrado que a apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do réu envolvia os adolescentes Vitor Tavares França e Gabriel Sampaio de Vasconcelos, com respectivamente 17 e 15 anos de idade, na data dos fatos, sendo, assim, aplicável a mencionada causa de aumento de pena.

Do afastamento da circunstância agravante da pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos.” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Então, a circunstância agravante deve ser afastada.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme certidão a fl. 63 e folha de antecedentes as fls. 64/66. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizam a redução de 2/3 (dois terços) da pena fixada, culminando com a pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, que ante a ausência de outras circunstâncias, torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade do Réu e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)." (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por

uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu CARLOS VICTOR FREIRE ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 194 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade (Alvará de Soltura Cumprido à fls. 91/94) e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, faculta-se o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado em fls.

99/100 (R\$ 96,50) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA